

1501618-20.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501618-20.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288435/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 20967182 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 118/21/592 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2288435 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSVALDO GUEDES SILVA SOBRINHO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 09 dias do mês de junho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a), dr. Wesley César Sabino Braga. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) OSVALDO GUEDES SILVA SOBRINHO, e a testemunha arrolada em comum pelas partes: Luiz Antonio Queiroz. . Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram)

colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Luiz Antonio) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, OSVALDO GUEDES SILVA SOBRINHO está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de outubro de 2021, por volta de 16h40m, na rua Infante Dom Henrique, altura do numeral 999, bairro Vila Cristina, nesta cidade e comarca, OSVALDO GUEDES SILVA SOBRINHO, qualificado a fls. 05, guardava e/ou mantinha em depósito 12 porções “cocaína” destinados à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, policiais, em diligências, avistaram o denunciado em atitude típica de tráfico ilícito de drogas, ou seja, “um indivíduo oferecendo algo a outro, e este, em troca, deu-lhe dinheiro, tratando-se de uma venda de droga”. Outrossim, verificaram que o denunciado se dirigiu até um poste de energia elétrica, onde pegou algo. Diante da fundada suspeita, realizaram abordagem e, em revista pessoal, com o denunciado, localizaram a quantia de R\$ 30,00. Ato contínuo, próximo ao poste, encontraram 12 (doze) porções de cocaína. Informalmente, o denunciado confessou a prática delitiva.

Luis Ricardo Varela também foi abordado e, com ele, os policiais apreenderam uma porção de cocaína. Indagado, ele admitiu que havia adquirido a droga do denunciado pelo valor de R\$ 10,00. Perante a autoridade policial, o denunciado ficou em silêncio.

Diante das circunstâncias da prisão, da apreensão de substância entorpecente em porções individualizadas para venda, da declaração de Luís Ricardo e das condições pessoais do denunciado, que é reincidente específico, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Luis Antonio Queiroz, policial civil, narrou que o local é ponto de tráfico. O réu tem salão de cabeleireiro e recebeu noticia de que ele traficava drogas. Passou pelo local várias vezes e viu o réu ora em um lado, ora em outro lado da rua. Viu ele vendendo drogas a um usuário, mas não conseguiu abordar este consumidor. Abordou apenas o réu, encontrou drogas perto de um poste. O réu estava em frente ao salão, mas do outro lado da calçada quando o viu vendendo drogas. Mas ao ser abordado, ele já estava no salão. Ele mesmo indicou onde estavam os entorpecentes, do outro lado da rua, em uma caixa de força, em um poste de entrada de energia, onde ele já tinha sido visto. Encontrou eppendorfs com cocaína. Não havia mais ninguém no salão. Não se recorda bem se abordou o usuário de drogas. Não lembra se apreendeu dinheiro com o réu. Este é conhecido como Osvaldinho e já tinha informação de envolvimento dele com o tráfico.

Christiano de Munhoz Rodrigues narrou no mesmo sentido.

OSVALDO negou os fatos. Atendeu e cortou o cabelo de Amarildo. Depois de quinze minutos uns moleques que estavam na frente correram quando viram os policiais chegando. Foi revistado, bem assim o seu salão. Os policiais encontraram drogas do outro lado da rua e disseram que iriam “jogar” no interrogando porque ele estaria acobertando os “meninos”.

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal

nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

A negativa do réu restou isolada. Sequer Amarildo confirmou a versão dele nos autos.

As provas angariadas não deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

Da Dosimetria da Pena

O réu é reincidente específico (fls. 36-42).

Pena acima do mínimo legal.

Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Entendo não ser possível, também, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo,

com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

OSVALDO GUEDES SILVA SOBRINHO, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, que lhe move a Justiça Pública, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, apresentar seus MEMORIAIS, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados.

I - DA SUMA FÁTICA

O réu foi preso em flagrante delito no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 16h40min., na Rua Infante Dom Henrique, 999, Vila Cristina, Piracicaba - SP, por ter, ao menos em tese, cometido o delito descrito no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Consta dos autos que, policiais civis da 3.a Homicídios, realizavam investigação de crime de homicídio, quando se depararam com uma venda de drogas sendo concretizada, na calçada.

Puderam ver um indivíduo entregando algo para outro e recebendo algo que parecia ser dinheiro, resolveram fazer a abordagem. Havia visto a venda desde o início, quando notaram que o autor, identificado como sendo Osvaldo Guedes Silva Sobrinho, acessava um poste de energia elétrica.

Ao revistar o suposto comprador, Luís Ricardo Varela Paiva, encontraram em sua posse um eppendorf contendo pó esbranquiçado aparentando ser cocaína, com peso bruto de 1,3 gramas.

No poste acessado anteriormente por Osvaldo, encontraram mais 12 eppendorfs semelhantes ao primeiro, contendo pó esbranquiçado aparentando ser cocaína, com peso bruto de 15,1 gramas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão contra o réu.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu.

A denúncia foi recebida. Após a notificação do réu, o mesmo apresentou sua defesa prévia.

Em audiência de instrução, o réu foi interrogado, bem como foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

O Ministério Público, em seus memoriais, pugnou pela procedência da ação nos termos

da denúncia.

Em apertada síntese, este é o relatório dos fatos.

II - DA PESSOA DO RÉU

Emérito Julgador, o réu é possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa, labora lícitamente, além de ser arrimo de família.

III - DO MÉRITO

Quanto ao mérito, o réu é inocente e deve ser absolvido das acusações constantes da denúncia, senão vejamos;

III.I - DA PROVA ACUSATÓRIA- DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO - FRAGILIDADE Excelência, o réu está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

O Ministério Público, em suas alegações finais, pediu a condenação do Réu.

Nesse sentido, a defesa entende ser o caso de absolvição, haja vista que encontram-se ausentes provas ou até mesmo mínimos indícios de autoria delitiva no que concerne ao delito em questão.

Excelência, ao analisarmos as provas acusatórias apenas temos os depoimentos das testemunhas de acusação, que são policiais, o que requer vista com certa reserva, haja vista que, sem sombra de dúvidas os agentes envolvidos na prisão acabam por ter a necessidade de querer validar seu serviço feito anteriormente na fase inquisitiva.

Nesse sentido, os depoimentos dos policiais em nenhum momento demonstraram de forma contundente que o acusado era de fato o proprietário dos entorpecentes supostamente encontrados no local dos fatos.

Dito isso, ressalta-se a importância de analisarmos os depoimentos das testemunhas de acusação que, repita-se, mentirosos e eivados de vícios, senão vejamos;

DEPOIMENTO DO POLICIAL LUIS ANTONIO QUEIROZ

"É policial civil lotado na 3.a Homicídios - Deic - Deinter 9. Nesta data, investigava um crime de homicídio, quando, passando pela rua Infante Dom Henrique presenciou um indivíduo oferecendo algo a outro, e este, em troca, deu-lhe dinheiro, tratando-se de uma venda de droga. Observou quando o suposto vendedor acessou um poste de energia elétrica e retirou algo dali, em seguida, passando tal objeto ao suposto comprador. Em companhia do policial CHRISTIANO, resolveram abordá-los. Ao revistarem o suposto comprador, identificado como sendo LUÍS RICARDO VARELA PAIVA, encontraram em sua posse um pino de cocaína, tendo este dito que havia adquirido pelo valor de dez reais do desconhecido. Por sua vez, o indivíduo identificado como sendo OSVALDO GUEDES SILVA SOBRINHO confirmou estar na mercancia da droga, inclusive estando na posse de 30 reais em espécie, e no local antes por ele acessado, encontraram mais 12 pinos da mesma droga, semelhantes ao localizado na posse de LUÍS RICARDO. Deu-lhe voz de prisão em flagrante, apresentando ambos nesta Especializada. Não os conhecia antes dos fatos."

Em juízo, o policial reproduziu sua versão apresentada na delegacia, mas acrescentou que o réu foi abordado no salão e teria indicado que na rua tinha entorpecentes.

Acrescentou que não conseguiu abordar a pessoa que viu comprando drogas dele, o que causa divergência com o depoimento na delegacia, onde afirmou que abordaram o suposto usuário.

Acrescentou que não foi encontrado droga do salão do réu.

Acrescentou que não tinha mais meninos na rua quando da abordagem, o que mostra divergência com o depoimento do seu parceiro que falou que tinha mais meninos na rua quando da abordagem e eles acabaram se dispersando.

DEPOIMENTO DO POLICIAL CHRISTIANO DE MUNHOZ RODRIGUES

"É policial civil lotado na 3.a Homicídios - Deic - Deinter 9. Na data de hoje, investigava um crime de homicídio, juntamente com o policial LUÍS. Ao passarem pela rua Infante Dom Henrique presenciaram um indivíduo oferecendo algo a outro, e este, em troca, deu-lhe dinheiro, tratando-se de uma possível venda de droga. Notaram quando o suposto vendedor acessou um poste de energia elétrica e retirou algo dali. Em seguida passou tal objeto ao suposto comprador. O depoente e LUÍS resolveram abordá-los. Ao revistarem o suposto comprador, que disse chamar-se LUÍS RICARDO VARELA PAIVA, encontraram em sua posse um eppendorf contendo cocaína, tendo este

ainda dito que havia adquirido-o pelo valor de dez reais do desconhecido. Por sua vez, o indivíduo que foi identificado como sendo OSVALDO GUEDES SILVA SOBRINHO confirmou que estava comercializando drogas, inclusive estando na posse de 30 reais em espécie, e no local antes por ele acessado, encontraram mais 12 pinos da mesma droga, semelhantes ao localizado na posse de LUÍS RICARDO. Deu-lhe voz de prisão em flagrante, apresentando ambos nesta Especializada. Não os conhecia antes dos fatos..”

Em juízo, a policial reproduziu sua versão apresentada na delegacia.

Acrescentou ainda que foi até o salão de cabeleireiro do réu, que estava aberto, mas não encontrou drogas no local e não se recorda se tinha outras pessoas no salão.

Falou ainda que quando se aproximaram para a abordagem, outras pessoas que estavam no local acabaram se evadindo.

DEPOIMENTO DO LUIS RICARDO VARELA PAIVA

“O depoente é usuário de cocaína desde os 17 anos. Nesta data, passava pela rua Infante Dom Henrique, sendo que observou que um indivíduo desconhecido lhe fez sinal com as mãos, querendo dizer que estava vendendo cocaína. O depoente se aproximou e pediu um eppendorf. O indivíduo disse que era para o depoente descer até a esquina, que ele iria pegar uma porção, em seguida saiu andando. O depoente foi ao seu encontro, quando chegaram dois homens num veículo dizendo serem policiais e que seria revistado. Com o depoente encontraram um pino com cocaína, que havia acabado de adquirir pela quantia de dez reais. Essa pessoa que também vendeu o entorpecente foi abordada pelos policiais e trazida a esta delegacia. Esclarece que não conhecia a pessoa que estava comercializando a substância entorpecente. Já foi preso anteriormente por roubo.”

Excelência, de análise aos depoimentos dos policiais, podemos concluir que a versão apresentada por eles no sentido de afirmarem que o réu estava vendendo cocaína, com todo o respeito, mas referida versão me parece fantasiosa, explico;

Inicialmente conforme ficou demonstrado no interrogatório do réu, o mesmo estava cortando o cabelo de seu cliente, quando os policiais tentaram abordar os meninos que estavam na frente do salão, e como não conseguiram prender os meninos e o réu não soube dizer quem eles eram, acabou sendo preso injustamente.

Com todo o respeito, mais tal versão já começou de forma totalmente absurda e fantasiosa.

A versão apresentada pelos policiais não corroboram com as demais provas dos autos, por isso, isoladas e fraca por demais a escoar um édito condenatório.

Isto porque, na delegacia eles afirmam que o usuário foi abordado, já em juízo, o policial Luiz disse que não foi possível abordar o suposto usuário.

Ressalta-se ainda que o policial Luiz acrescentou que não foi encontrado droga do salão do réu.

Acrescentou que não tinha mais meninos na rua quando da abordagem, o que mostra divergência com o depoimento do seu parceiro que falou que tinha mais meninos na rua quando da abordagem e eles acabaram se dispersando.

Portanto, ante todo o exposto, constatado que a versão das testemunhas de acusação não corroboram com as demais provas dos autos, restando assim isoladas, deve a presente ação penal ser julgada improcedente, por falta de provas, nos termos do artigo 386, VIII do Código de Processo Penal

III.II - DA PROVA DEFENSIVA - INTERROGATÓRIO DO RÉU E TESTEMUNHA DE DEFESA

Quanto as provas defensivas, diferente das acusatórias, estas são uníssonas e corroboram com as demais provas dos autos, senão vejamos;

IIII.II.I - INTERROGATÓRIO DO RÉU OSVALDO EM JUÍZO

“Que estava dentro do salão cortando cabelo de um cliente. Tinha uma molecada na rua, em frente ao salão e quando avistaram o carro Sienna da polícia que eles já sabiam que era da polícia, daí eles saíram correndo e os policiais abordaram o réu dentro do salão e perguntaram quem eram os moleques e falou que não conhecia porque fazia pouco tempo que tinha montado o salão. Os policiais começaram a procurar pela rua e acharam droga em um posto bem pra cima do meu salão e falaram que se não falasse quem eram os meninos iam levar o réu. Como não falou quem eram eles, foi levado para a delegacia porque falou que estava passando pano para os meninos.

Veja Excelência que o interrogatório do Réu corresponde com a realidade dos fatos e demais provas dos autos, merecendo assim total credibilidade, uma vez que ficou claramente demonstrado que o acusado é inocente da acusação que lhe pesa, pois, teria sido forjado pelos policiais, pois o interrogatório do réu corrobora com as demais provas dos autos.

Pois, como vimos, o fato de não ter falado quem eram os moleques, acabou sendo forjado e responsabilizado pelas drogas de forma injusta.

Ante o exposto, a conclusão que se chega é a justa absolvição do réu, diante de todas as provas dos autos à demonstrarem sua inocência.

Temos ainda nos autos prova documental e testemunhal de ocupação lícita do réu. Por outro lado, a prova acusatória que se baseia nos depoimentos dos policiais, deverá ser analisada com certa reserva, pois sabemos que os agentes públicos, em juízo, sempre terão a intenção na validação da prisão realizada, além do fato de que tinham motivo para forjar o réu, o que torna por si só os seus depoimentos suspeitos.

Nesse diapasão, o que se demonstrou nos autos foi a inocência do réu, bem como a ausência de prova em seu desfavor, de modo que a improcedência da ação é imperativo de justiça, uma vez em que não é demais ressaltar que o contexto probatório é fraco por demais a escoar um édito condenatório

III.III - DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO QUE DEFINE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA

Excelência, a pena base deverá ser fixada no seu mínimo legal, de acordo com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, uma vez que não seria lícito o MM. Juízo "aquo" majorar a pena base, sob o argumento inidôneo de que a quantidade e variedade de drogas autorizam referida majoração.

Vale destacar que em nosso ordenamento jurídico não existe ainda um parâmetro para definir que a partir de qual quantidade seria considerado grande quantidade de drogas e por isso referida fundamentação não encontra respaldo jurídico.

III.IV - DA DOSIMETRIA DA PENA - RÉU DE BONS ANTECEDENTES, QUE NÃO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS NEM INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO DE 2/3 DA PENA NOS TERMOS DO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º DA LEI 11.343/06 - "BIS IN IDEM - PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA"

Emérito Julgador, inexistem circunstâncias agravantes ou causas de aumento de pena. No entanto, levando em consideração tratar-se de réu possuidor de bons antecedentes, que não se dedica a atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa, o mesmo faz jus ao redutor máximo de 2/3 da pena, alcançando assim uma reprimenda de até 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

Nesse sentido, deve ser aplicado o redutor de 2/3 da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

III.V - DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO OU SEMIABERTO COMO O INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, § 1, DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS

Excelência, caso o réu alcance uma reprimenda igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deve ser fixado a ele o regime aberto como o inicial de cumprimento de pena, haja vista preencher os requisitos previstos no artigo 33, §2º, "c" e §3º e artigo 59, ambos do Código Penal.

Nesse sentido, deve ser fixado ao réu o regime aberto como o inicial de cumprimento de pena, por ser medida de justiça!!

Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência e a pena do réu não ultrapassar 08 (oito) anos de reclusão, seja fixado o regime semiaberto

III.VI - DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL E RESOLUÇÃO 5/2012 DO SENADO FEDERAL

Emérito Julgador, caso seja imposta ao réu uma reprimenda igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deve ser aplicado no presente caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que o acusado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Ademais, já decidiu a Suprema Corte pela inconstitucionalidade da vedação da substituição da pena privativa de liberdade em caso de condenação por crime de tráfico de entorpecentes, confira;

Declaração incidental de inconstitucionalidade da vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos nos crimes de tráfico de drogas "12. Confirmando, então, que o centrado desafio temático deste voto é saber se a proibição estabelecida pela nova lei, isto é, a Lei 11.343/06, encontra ou não encontra suporte no sistema de comandos da Constituição Federal. O que demandará elaboração teórica mais cuidadosa para a perfeita compreensão da natureza e do alcance da garantia constitucional da individualização da pena. (...) 13. Leia-se a figura do crime hediondo, tal como descrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal: (...). 14. Daqui já se pode vocalizar um primeiro juízo técnico: em tema de vedações de benefícios penais ao preso, ou, então, ao agente penalmente condenado, o Magno Texto Federal impõe à lei que verse por modo igual os delitos por ele de pronto indicados como hediondos e outros que venham a receber a mesma tarja. Sem diferenciação entre o que já é hediondo por qualificação diretamente constitucional e hediondo por descrição legal. Isonomia interna de tratamento, portanto, antecipadamente assegurada pela nossa Constituição. 15. Um novo e complementar juízo: embora o Magno Texto Federal habilite a lei para completar a lista dos crimes hediondos, a ela impõe um limite material: a não-concessão dos benefícios da fiança, da graça e da anistia para os que incidirem em tais direitos. É como dizer, a própria norma constitucional cuidou de enunciar as restrições a ser impostas àqueles que venham a cometer as infrações penais adjetivadas de hediondas. Não incluindo nesse catálogo de restrições a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Ponto pacífico. Percepção acima de qualquer discussão ou contradita. 16. Insista-se na ideia: no tema em causa, a Constituição da República fez clara opção por não admitir tratamento penal ordinário mais rigoroso do que o nela mesma previsto." (HC 97256, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgamento em 1.9.2010, DJe de 16.12.2010)

E ainda;

"HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, 4.º, DA NOVA LEI DE TÓXICOS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE CASO O APENADO SATISFAÇA OS REQUISITOS LEGAIS. CISÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. Diante de conflito aparente de normas, não é dado ao juiz aplicar os aspectos benéficos de uma e outra lei, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova. 2. Encaixando-se a hipótese no disposto no 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, a pena reclusiva de 05 anos reduz-se para menos de 03 anos, passando, assim, a ser a mais benéfica do que a antiga. 3. Excluído o único óbice à progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados, consubstanciado no caráter especial dos rigores do regime integralmente fechado, não subsiste qualquer empecilho ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, desde que o acusado atenda os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Precedentes (...) 5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Tribunal de origem que prossiga no exame dos requisitos legais previstos no art. 33, 4.º, da Lei n.º 11.343/06, fixando, se for o caso, o percentual de redução (de 1/6 a 2/3), o qual deverá incidir sobre o caput do mesmo artigo, bem assim no que diz respeito à concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Habeas Corpus Nº 83.899 - SP (2007/0124714-0) - Relatora: Ministra Laurita Vaz. Impetrante: Thiago Alonso Giglio Advogado: Nilton Massih e outro (s) Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Paciente: Thiago Alonso Giglio J. 05/08/2008".

Ante o exposto, deve ser a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, por ser medida de justiça!!

III.VII – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Excelência, o réu é possuidor de residência fixa no distrito da culpa, não apresentando qualquer risco a ordem pública, econômica ou até mesmo na aplicação da

lei penal, por isso este Douto Juízo poderá conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade e é o que a defesa espera.

IV - DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, e acreditando no alto critério de Vossa Excelência, requer:

a) Seja a presente ação penal julgada totalmente improcedente, absolvendo-se o réu OSVALDO GUEDES SILVA SOBRINHO, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, por ser medida de justiça!!

Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer;

b) Seja a pena privativa de liberdade aplicada no seu mínimo legal;

c) Seja aplicado o redutor da pena previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo;

d) Seja aplicado o regime aberto ou semiaberto como o inicial de cumprimento de pena;

e) Seja a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito;

f) Requer seja concedido ao réu o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, pois o mesmo é possuidor de residência fixa e trabalho lícito, não existindo nos autos elementos de que caso seja ele posto em liberdade e sua sentença venha a ser confirmada em superior instância, o mesmo se furtaria a aplicação da lei penal!!!!

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

OSVALDO GUEDES SILVA SOBRINHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 21 de outubro de 2021, por volta de 16h40, na rua Infante Dom Henrique, altura do numeral 999, bairro Vila Cristina, nesta cidade e comarca, guardava e/ou mantinha em depósito 12 porções "cocaína" destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais, em diligências, avistaram o réu em atitude típica de tráfico ilícito de drogas, ou seja, "um indivíduo oferecendo algo a outro, e este, em troca, deu-lhe dinheiro, tratando-se de uma venda de droga". Outrossim, verificaram que o réu se dirigiu até um poste de energia elétrica, onde pegou algo. Diante da fundada suspeita, realizaram abordagem e, em revista pessoal, com o réu, localizaram a quantia de R\$ 30,00. Ato contínuo, próximo ao poste, encontraram 12 (doze) porções de cocaína. Informalmente, o réu confessou a prática delitiva. Luís Ricardo Varela também foi abordado e, com ele, os policiais apreenderam uma porção de cocaína. Indagado, ele admitiu que havia adquirido a droga do réu pelo valor de R\$ 10,00.

Perante a autoridade policial, o réu ficou em silêncio.

Diante das circunstâncias da prisão, da apreensão de substância entorpecente em porções individualizadas para venda, da declaração de Luís Ricardo e das condições pessoais do réu, que é reincidente específico, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida (fls. 111), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 119/120). O réu foi notificado (fls. 128) e apresentou defesa prévia, na qual requereu a improcedência da ação (fls. 135/138).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência (fls. 202/204). O réu foi citado (fls. 162).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns (fls. 175/178), sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 09, no laudo de constatação preliminar de fls. 15/19, nas fotografias de fls. 23 e 25 e no exame químico-toxicológico de fls. 116/118, que detectou a presença de cocaína na substância apreendida.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05).

Em Juízo, o réu narrou que estava dentro do seu salão. Tinha acabado de abrir e um cliente de nome Amarildo chegou. Começou a cortar o cabelo dele. 15 minutos depois, os moleques avistaram um Siena e saíram correndo. Os policiais o abordaram dentro do salão. Todo o salão foi revistado, nada sendo encontrado. Os policiais queriam saber a respeito dos moleques que tinham corrido. Respondeu que nada sabia, que tinha começado a trabalhar há pouco tempo, que o salão era novo. Os policiais saíram do salão e encontraram a droga no poste, do outro lado da rua e voltaram, dizendo que se não falasse de quem era, que iriam acusá-lo. Disse que não sabia de quem era. Estava pagando aluguel do salão, se a mãe soubesse de droga teria o mandado para fora de casa. Não estava vendendo a droga. O dinheiro apreendido com ele era seu, de um cabelo que tinha cortado de manhã e outro à tarde. Amarildo já tinha pagado o corte, que custa R\$ 15,00. Foi algemado e levado à Delegacia. Fumava maconha, mas conseguia ficar sem consumi-la. tem contra os policiais a injustiça que fizeram.

A negativa de autoria restou isolada nos autos. Vejamos.

O policial civil Luís Antônio Queiroz assegurou que naquele quarteirão e no próximo, são conhecidos como pontos de venda de drogas. também havia informação de que Osvaldinho teria um salão de cabeleireiro e que estaria vendendo drogas no local. passaram algumas vezes no local e visualizaram o réu perto de um poste de energia, mas não o tinham abordado, porque ele estava sozinho. No dia dos fatos, viram o réu fazendo a venda de entorpecentes, mas não conseguiram abordar a pessoa que comprou. O réu estava do outro lado da calçada do salão. Ele foi abordado no salão e indicou que os entorpecentes estavam do outro lado da rua, no poste de entrada de energia. Encontraram cocaína. Não havia ninguém no salão. Não se recorda se a pessoa que comprou drogas foi ou não abordada. Não se recordou se havia dinheiro. Já tinha visto o réu no local, mas nunca o tinha abordado. Não se recordou onde o usuário foi abordado. No salão não havia drogas. Não havia mais pessoas na rua, além do réu e do usuário.

No mesmo sentido, o depoimento do também policial civil Christiano de Munhoz Rodrigues, segundo o qual estava com Luís e passavam pela rua, quando avistaram, de longe, num conhecido ponto de tráfico, duas pessoas mantendo contato, com gesticulação típica de venda de tráfico. No local, estavam Luís comprando drogas e o réu vendendo. Com Luís, encontraram 01 microtubo de cocaína e ele disse que tinha comprado a droga do réu. O réu confirmou que vendia drogas e foram até um local onde o réu se aproximou, um mato, encontrando o restante da droga, embalada da mesma forma que a droga que estava com o réu. O réu se aproximou de um posto de energia e retirou alguma coisa, para fazer a transação com Luís. Então, já tinham visto o réu nesse ponto, onde o restante da droga foi encontrada. Esse local é de trânsito de muitas pessoas. Não poderia indicar quem estava ali, mas havia certamente outras pessoas. Não conhecia o réu e o usuário. Não se recorda se estava com outros policiais. Estavam numa viatura descaracterizada, um Siena prata. Seu diretor pede colaboração para combate do tráfico de drogas e, por isso, circulam pelos locais já conhecidos por ser ponto de venda de drogas. Não se recorda de estar cumprindo alguma ordem de serviço, o que é possível ocorrer, quando se deparam com uma situação dessa de crime. Estava a uma distância que era suficiente para verificar a situação suspeita e para não serem visualizados. Não se recorda se estavam com a viatura parada ou se estavam em movimento devagar. Pela distância, não viu o que era entregue de um para outro. Só viu o gestual. Não se recorda da vestimenta que eles usavam. Crê que quem achou o entorpecente tenha sido Luís.

Acredita que não foram até a casa do réu. Foram ao salão de cabeleireiro, que o réu tinha alugado para corte de cabelo e não se recorda de terem achado alguma coisa. O salão estava aberto e acredita que não havia ninguém ali (fls. 175/178).

Ouvido apenas inquisitivamente, Luís Ricardo Varela Paiva explicou que é usuário de cocaína desde os 17 anos. Na data dos fatos, passava pela rua Infante Dom Henrique e observou que um indivíduo desconhecido lhe fez sinal com as mãos, querendo dizer que estava vendendo cocaína. Aproximou-se e pediu um eppendorf. O réu disse que era para ele descer até a esquina, que iria pegar uma porção e, em seguida, saiu andando. Foi ao encontro do réu, quando chegaram dois homens num veículo dizendo serem policiais e que seria revistado. Com ele, encontraram um pino com cocaína, que havia acabado de adquirir pela quantia de R\$ 10,00. O réu que lhe vendeu o entorpecente também foi abordado pelos policiais e levado à Delegacia. Não conhecia a pessoa que estava comercializando a substância entorpecente. Já foi preso anteriormente por roubo (fls. 04).

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Na fase policial, o réu permaneceu silente. Judicialmente, alegou não ter nenhuma responsabilidade pela droga, negando que a droga lhe pertencesse. Aduziu que estava cortando o cabelo de um cliente de nome Amarildo, quando foi abordado pelos policiais, dentro do seu salão.

O policial Luís alegou que já havia muita denúncia no sentido de que o réu teria um salão de cabeleireiro no local e faria a venda de drogas, inclusive, já o havia visto algumas vezes na rua e perto de um poste de energia, do outro lado do salão. No dia dos fatos, os policiais civis relataram que estavam em patrulhamento, em viatura descaracterizada, quando presenciaram o réu oferecendo algo a um terceiro e recebendo dele alguma coisa. Notaram, também, que o réu acessou um poste de energia e retirou algo dali, passando para esse terceiro. Diante da suspeita, abordaram ambos. Com o terceiro, encontraram 01 microtubo contendo cocaína, que ele confirmou ter acabado de adquirir do réu, por R\$ 10,00. Em relação ao réu, ele confirmou estar comercializando drogas. Na sua posse, os policiais encontraram R\$ 30,00 em espécie e, no local antes por ele acessado, ou seja, no poste de energia, localizaram mais 12 pinos de cocaína, embalados de forma idêntica àquele que foi encontrado com a testemunha. Os policiais negaram que houvesse cliente no salão de cabeleireiro do réu.

Em solo policial, o usuário de drogas aduziu que se aproximou do réu e lhe pediu um microtubo de cocaína. O réu mandou que descesse a esquina, porque iria pegar a droga. Depois, foi ao encontro do réu e logo foram abordados. Na sua posse, os policiais encontraram um microtubo de cocaína que tinha acabado de adquirir do réu, por R\$ 10,00. Em audiência, Luís não foi localizado para ser ouvido.

Com efeito, a prova confirma que o réu tinha envolvimento coma droga apreendida. Inicialmente, os policiais já tinham denúncias de tráfico de drogas praticado pelo réu, no endereço da denúncia e, naquele dia, os policiais civis visualizaram o contato do réu com o usuário de drogas.

Depois, com a abordagem, os policiais encontraram com o usuário um microtubo de cocaína, embalado de forma idêntica aos demais microtubos encontrados no exato lugar que os policiais viram o réu acessando.

Nesse contexto, os policiais não teriam como encontrar o restante da droga, se não tivessem visualizado o réu acessando o local.

Ademais, o fato de a droga estar embalada da mesma forma indica que toda ela estava, anteriormente, sob a guarda do réu.

Nesse contexto, a prova foi suficiente para a certeza do envolvimento do réu com o entorpecente.

Por fim, como já vem decidindo a jurisprudência, a palavra de policiais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, desde que corroborado pelo restante da prova, como no caso em comento, pela localização da droga e pelo depoimento do usuário.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg.

Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro

JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

Não havendo nenhuma prova de que os policiais civis tivessem interesse em prejudicar o réu, que não conheciam, e diante do depoimento do usuário, a palavra dos agentes policiais deve ser considerada.

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu alegou que não tinha nenhuma ligação do as drogas apreendidas. A prova, contudo, indica que a droga tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas. Vejamos.

Inicialmente, os policiais civis presenciaram a conduta do réu que fez contato com o usuário de drogas, dirigiu-se ao local onde a droga estava escondida, pegou alguma coisa e a entregou ao usuário, recebendo dele R\$ 10,00.

A negociação foi presenciada pelos policiais, que também encontraram um microtubo de cocaína com Luís, embalado de maneira idêntica ao restante da droga escondida.

A situação fática vislumbrada pelos policiais dá a certeza da acusação, ainda porque o usuário confirmou a compra da droga do réu.

Ademais, o réu confessou, informalmente, que estava comercializando o entorpecente. Destarte, quisesse o réu comprovar sua versão, poderia ter arrolado como testemunha a pessoa de Amarildo, que segundo ele era seu cliente e estava cortando o cabelo, quando os policiais o abordaram. Sua versão seria facilmente comprovada com a oitiva dessa testemunha que os policiais civis disseram que não existia dentro do salão.

Assim, a situação fática presenciada pelos policiais civis, o depoimento da testemunha, a quantidade da droga e sua forma de embalagem, o dinheiro apreendido e

a confissão informal; tudo revela que a droga tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito. Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu não